

1500120-16.2022.8.26.0416

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tiago Henrique Grigorini

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... que na frente da casa dela, fazendo o tráfico na rua. Quando questionou-a sobre o entorpecente, ela disse que tinha crack fracionada dentro do sutiã. Indagada a quem pertencia a droga, respondeu que era do marido dela. Revistado o local, foi localizada uma porção de maconha e dinheiro. Indagada se a ré admitiu informalmente o tráfico, disse que sim. Indagada pela defesa, se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

2ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500120-16.2022.8.26.0416 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500120-16.2022.8.26.0416

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053848/2022 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 23231090 -

DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2053848 - DEL.POL.PANORAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIELLY FERNANDA FLORENTINO GUATURA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Henrique Grigorini

Vistos.

RELATÓRIO

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA BATISTA e ARIELLY FERNANDA FLORENTINO GUATURA, qualificados nos autos, foram denunciados pela JUSTIÇA PÚBLICA por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto, nas condições de tempo e espaço descritas na denúncia, trazia consigo 8,5 gramas de crack e mantinham em depósito outras 37,1 gramas de maconha em sua residência, que seriam destinadas à mercancia proscrita.

Na audiência de custódia, realizada em 24/02/2022, a ré teve sua prisão preventiva decretada, porém substituída por domiciliar, e o réu foi beneficiado com a liberdade provisória (p. 85/92).

Por determinação da instância superior, foi restabelecida a custódia cautelar do réu (p. 258/263).

Regularmente notificados, os réus apresentaram Defesa Prévia (p. 194/195), sendo recebida a denúncia no dia 02/05/2022 (p. 196/197).

Em audiência de instrução, realizada em 24/08/2022 (p. 343/344), foram ouvidas duas testemunhas e interrogados os réus, com anuência da defesa.

Em nova audiência, foi ouvida uma testemunha e re-interrogados os réus (p. 388/391). Encerrada a instrução, o MP apresentou suas alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia. Nesse interim, foi julgado o H.C. impetrado pelo réu, e por força do V. Acórdão do STJ de p. 401/407, foi concedida a ordem para restabelecer as medidas cautelares diversas, implementadas por este juízo, revogando-se a preventiva do réu. A defesa apresentou memoriais (p. 424/434), pugnando pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas, tendo em vista o princípio da inviolabilidade do domicílio. Ademais, caso não seja este o entendimento, pela absolvição do acusado, ante ausência de provas acerca de sua participação, e quanto à ré, o reconhecimento da atenuante da confissão e do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas. Relatado o necessário, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

O feito encontra-se devidamente instruído e apto ao julgamento. A preliminar de nulidade será apreciada juntamente com o mérito, eis que intrinsecamente atrelada aos demais elementos de prova.

No mérito, a presente ação penal é procedente, devendo a ré ser condenada como incurso nas penas do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. O réu deve ser condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito veio comprovada pelo APFD (p. 01), pelo Boletim de Ocorrência p. 62/64, auto de exibição e apreensão (p. 14/15), laudos de constatação (p. 32/37 e 38/43), além dos demais documentos constantes nos autos.

Autoria e tipicidade são certas quanto ao crime de tráfico de drogas, e vêm amparadas pelas provas produzidas em juízo.

DA PROVA

A testemunha Haroldo Viana de Lira, ouvida em sede policial (p. 02), declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento das ruas de Panorama, juntamente com a PM Maysa, pela Rua João Vieira, Bairro Potiguara, depararam-se com duas mulheres em frente de suas residências; Abordou a mulher identificada como Erica, enquanto a Soldado Maysa abordou a outra mulher identificada como Ariely, e de imediato também se fez presente o apoio de outras viaturas, sendo que o depoente conversou com Erica e ela confidenciou que tinha acabado de comprar cinco (05) pedras de "Crack" da traficante Aurea, entregando a droga para o depoente; Informa que Aurea estava em seu campo visual e resolveu dar voz de prisão para Aurea, mas ela correu para dentro da casa, que fica nos fundos do terreno; Correu atrás de Aurea e percebeu que ela tinha dado descarga no banheiro, presumindo ter jogado algo dentro do vaso sanitário, sendo franqueada a busca na residência e nada de ilícito foi encontrado, bem como na revista pessoal também nada de ilícito foi encontrado em poder de Aurea, que negou ter vendido droga para Erica; Informa que foi dar apoio para a Soldado Maysa, na abordagem da outra mulher identificada como Ariely, que ao ser indagada a respeito de tráfico de droga, de imediato já confessou que trazia droga dentro do seu sutiã, setenta (70) pedras de "Crack", entregando para a Policial Maysa, alegando que a droga pertencia ao seu convivente, "Luiz Matogrosso". Outras viaturas policiais foram ao encalço de Luis e o encontraram no Ponto de ônibus da Rua Avelino Bobato, sendo revistado e nada foi encontrado, depois foi conduzido ao local dos fatos, onde o casal autorizou a busca no interior da residência, sendo encontrado dentro de um recipiente plástico em cima do rack da sala de estar, uma porção de "maconha" e R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em dinheiro; Informa que o casal confessou que vendiam droga no local, mas que a droga pertencia ao réu Luiz; declarou que o casal é conhecido no meio policial pelo crime de tráfico de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado na delegacia pela PM Maysa Marega de Cinque (p. 04), nada alterando em sua versão.

Em Juízo, Haroldo declarou que estava de patrulhamento nas ruas da cidade quando decidiram pela abordagem de uma mulher, que guardava dentro de sua bolsa cinco pedras de crack, que teria comprado da "Aurea", que estava na frente da casa e logo que deu voz de prisão correu para dentro de casa. Estava junto com a soldado Maysa que revistou a ré e achou no sutiã dela cerca de 70 pedras de crack. A ré alegou que pertencia ao marido "Luiz Mato Grosso". Noticiado os fatos a polícia,

encontram-o perto de um ponto de ônibus. Ambos confessaram que estavam vendendo drogas de sua residência, justificando dificuldade financeira. Indagado pela promotora, como encontraram o Luiz na rua de cima, disse que foi com o apoio de outras viaturas que deram apoio na ocorrência. A residência era do casal, eles autorizaram a entrada, inclusive com apoio do canil. Sobre a maconha encontrada na casa, ambos disseram que era para uso. Sobre o dinheiro, não souberam dizer a procedência. Indagado pela defesa, para descrever a residência da ré, falou que a residência é lateral, tem um quintal e um portão de grade fechado com "chapas", no bairro potiguara, propriedade com bastante mato. Indagado se tem duas casas no terreno, disse que não. Indagado se além da Erica, existia mais alguém na frente da casa, disse que não. A entrada foi autorizada após a chegada de Luiz. Em juízo, Maysa reiterou a mesma dinâmica dos fatos. Indagada pela promotora, onde estava a ré quando chegou no local, disse que na frente da casa dela, fazendo o tráfico na rua. Quando questionou-a sobre o entorpecente, ela disse que tinha crack fracionada dentro do sutiã. Indagada a quem pertencia a droga, respondeu que era do marido dela. Revistado o local, foi localizada uma porção de maconha e dinheiro. Indagada se a ré admitiu informalmente o tráfico, disse que sim. Indagada pela defesa, se a ré mostrou a droga, falou que sim, ela entregou para depoente. O réu Luis chegou posteriormente com a viatura. Assim que ele chegou foi solicitado autorização deles para entrar na residência. Quando Luis chegou ele não estava sujo, ele estava no ponto de ônibus chegando da escola. Esclareceu que o video juntado pelo MP foi gravado posterior à abordagem. Não se recorda em qual momento foi solicitada autorização para ingresso na residência, se antes ou após a gravação do video.

Vale lembrar que as palavras dos policiais - em razão de sua qualidade de agentes da Administração Pública - presumem-se verídicas e merecem crédito. Evidentemente, tal presunção admitiria prova em contrário, que, contudo, não foi produzida nos autos.

Para não serem cridos os depoimentos dos aludidos policiais, necessária seria a comprovação cabal do interesse deles na condenação, seja por inimizade seja por qualquer outra razão, uma vez que atuam na defesa da coletividade e não por interesse pessoal. A jurisprudência pátria toma a palavra dos policiais como prova tão idônea quanto qualquer outra, só cedendo na mencionada hipótese, a qual não restou comprovada nos autos. E não poderia ser de outra forma, pois completamente ilógico seria o Estado delegar a pessoas o exercício de sua função repressiva para depois negar crédito à palavra delas no cumprimento de seu mister.

Ademais, ao testemunharem, eles firmaram compromisso, sujeitando-se, por isso, às penas da lei. A propósito:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. Ordem denegada. (STJ - 5ª Turma - HC 115.516 / SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - Data da publicação: 09.03.2009 - grifo meu).

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E, na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Parcialidade ou má-fé não se presumem, provam-se; e, no caso em tela, a Defesa não trouxe nenhum elemento que demonstre cabalmente qualquer irregularidade na atividade policial.

A testemunha de Defesa, Erica da Silva, ouvida em juízo, informou que na data dos fatos tinha acabado de sair do banheiro da casa da "Aurea", vizinha dos réus. Indagada se viu como os policiais entraram na casa do Luiz e da Ariely, afirma que imagina que eles pularam o muro. Tinha alguns policiais do lado de dentro outros de fora, tinha bastante. Acha que eles pularam pelos fundos, porque o muro é baixo. Indagada pela promotora, como conseguiu ver como os policiais entraram na casa dos réus se estava saindo do banheiro, respondeu que só viu quando eles deixaram a depoente sair na rua.

O réu Luis Henrique de Oliveira Batista, ouvido em sede policial (p. 06), declarou que encontrava retornando do ponto de ônibus, onde foi buscar sua filha, quando foi surpreendido pela Polícia Militar, tendo sido informado sobre a apreensão da droga em poder de sua convivente Arielly, setenta pedras de Crack, momento em que disse que não sabia da droga. No local, os Policiais Militares adentraram em sua casa e encontraram "maconha" dentro de um recipiente plástico, momento em que confessou aos Policiais que é usuário de "maconha". Desconhecia a droga apreendida em poder de Arielly.

Em juízo, negou ter conhecimento das pedras de crack que foram localizadas em posse da ré e confessou que a maconha apreendida em sua residência lhe pertence, mas era destinada ao consumo pessoal. Na data dos fatos não estava em casa, tinha saído para ir buscar sua filha no ponto de ônibus. A maconha encontrada na sua casa lhe pertencia. Trabalhava com ajudante de pedreiro. Indagado sobre o crack encontrado com a ré, alegou desconhecer a existência desse crack. Arielly não comentou nada a respeito. No dia dos fatos trabalhou com o "Elton". Sobre o dinheiro, também não sabe da existência. Sua esposa recebia benefício do governo, "auxílio Brasil". Indagado sobre a versão do PM que afirmou que os réus vendiam droga, negou ter dito isto, também disse que não autorizou a entrada deles na sua casa, quando chegou eles já tinham revirado tudo. Indagado pela defesa, sobre a questão do teste de sexagem fetal, disse que no último exame deu que era menino, depois descobriram que o exame deu errado, e era uma menina, na última hora e já tinham comprado todo enxoval.

Interrogado novamente, negou a prática delitiva e falou que não autorizou a entrada da polícia em sua casa.

A ré, ouvida em sede policial (p. 08), declarou que no dia de hoje estava nos fundos de sua residência lavando roupas quando foi surpreendida por Policiais Militares, sendo indagada a respeito do tráfico de drogas. De imediato disse que trazia drogas consigo e retirou de dentro de seu sutiã, setenta (70) pedras de "Crack", confessando que venderia a droga para comprar o enxoval de sua filha que está prestes a nascer. Alega que por erro médico, tinha comprado roupas para um menino, mas na verdade vai ganhar uma menina, e pretendia angariar dinheiro para a compra porque seu marido, vulgo "LUIZ MATO GROSSO", vive fazendo "bicos" de serviço de pedreiro e não está conseguindo pagar as contas. Alega que o convivente é viciado em "maconha", a qual fora encontrada em sua residência e pertencia ao marido para o seu consumo. Sobre o dinheiro, alega ser proveniente de seu "Auxílio Brasil". Nunca foi processada anteriormente.

Em juízo, confessou os fatos, assumiu a propriedade das pedras de "crack" que foram localizadas em sua posse e seriam destinadas a venda. Contudo, disse que fez tudo isso escondida de seu marido. Alega que começou a vender drogas porque precisava de dinheiro para comprar novas roupas para sua filha recém-nascida. Nunca foi processada anteriormente. Indagada pela promotora, de quem teria comprado essas pedras de crack, disse que foi de uma pessoa que conheceu pelas redes sociais. Não sabe quanto custa 70 pedras de crack. Pretendia revender cada pedra por R\$ 10,00. Ficaria com metade do lucro da venda.

Interrogada novamente, indagada acerca do vídeo da polícia, disse que depois que já tinha sido presa, o policial Haroldo pediu para gravar esse vídeo, e falou que era para dizer que a droga pertencia ao seu marido, sendo ameaçada a "ganhar" seu filho na prisão. Seu sogro e vizinhos presenciaram os fatos.

Eis a prova oral colhida nos autos.

DA ADEQUAÇÃO TÍPICA

Depreende-se do conjunto probatório produzido nos autos que a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo, oportunidade que avistaram duas mulheres, cada qual defronte a sua residência. Que realizaram a abordagem de ambas, vindo a identifica-las com sendo Ariely Fernanda Florentina Guatura e Erica da Silva. Durante a revista pessoal de Érica, foi constatado que ela trazia consigo cinco trouxinhas de crack e R\$ 70,00 em dinheiro, indagada, alegou haver comprado tal substância da moradora da casa de nº 1093, identificando-a como sendo Aurea Maria Francisco. Ato contínuo foi feito contato com Aurea, que estava na residência, que ao tomar conhecimento correu para dentro de sua residência, entrando em um banheiro e deu descarga, sendo alcançada e abordada logo em seguida. Aurea negou aos policiais haver vendido drogas a Erica e franqueou a vistoria em sua residência, sendo que nada foi encontrada. Ato contínuo, na abordagem da ré Ariely, foi encontrado em seu poder 70 (setenta) pedras de "crack" em seu sutiã. Indagada, inicialmente confessou aos Policiais que estava apenas guardando aquela droga para seu companheiro, Luis Henrique de Oliveira Batista, que não estava no local, alegando, ainda, que Luis comercializava tal substância. Ariely indicou onde Luis poderia ser localizado, sendo o mesmo abordado em um ponto de ônibus na cidade, e conduzido de volta até sua residência. Inicialmente assumiu para si a propriedade da droga, indicando uma porção de maconha e dinheiro que havia em uma vasilha de plástico na residência do casal. Conduzidos à delegacia, os réus foram acompanhados por seu advogado, e mudaram suas narrativas, passando Ariely a afirmar que a substância encontrada consigo era de sua propriedade e destinava-se ao comércio, e que a maconha encontrada em sua residência era de Luis e destinava-se para seu consumo, já que o mesmo é usuário.

Finda instrução processual, os elementos de convicção amalhados aos autos são robusto e não deixam dúvidas acerca da conduta delituosa praticada pelos acusados. É fato incontroverso a localização de 70 pedras de "crack" em posse da acusada, que confessou a prática delitiva, justificando que estava vendendo porque passava por dificuldade financeira e também em razão de um erro do exame de sexagem fetal, ocorrido dias antes do parto, sendo que teria que comprar outro enxoval para o bebê.

De outro lado, a negativa do corréu, quando alega desconhecer a existência destas pedras de crack, não encontra respaldo no suporte fático-probatório dos autos. Primeiro, porque a própria ré, ao ser ouvida na delegacia, confirmou que a droga pertencia ao cônjuge, versão esta corroborada espontaneamente perante os policiais militares no calor dos fatos, conforme a mídia captada pelo agente responsável pela abordagem (vide p. 346). Por oportuno, saliento que a delação da comparsa goza de relevante valor probante, servindo como especial elemento de prova, sendo apto para sustentar o decreto condenatório.

Em juízo a ré alterou a versão dos fatos, aduzindo que traficava escondida do marido. Indagada de quem teria comprado a droga, disse que foi de uma pessoa que conheceu pelas redes sociais. Não sabe quanto custa 70 pedras de crack. Pegou "fiado" e pretendia revender cada pedra por R\$ 10,00 e ficaria com metade do lucro da venda. Além disso, alegou ter sido coagida pelo policial militar a gravar o vídeo incriminando o réu. Após a localização do entorpecente, foi realizada revista no imóvel, tendo sido localizado R\$ 260,00 (p. 14), quantia esta, segundo a ré, proveniente do "Auxílio Brasil" (sem comprovação nos autos). Ambos não comprovaram atividade lícita e o réu não trouxe qualquer prova para confirmar que trabalhava como servente de pedreiro, e, ainda, ostenta condenação anterior por tráfico de drogas.

Contudo, analisando os elementos de convicção dos autos, tenho que esta narrativa não se apresenta minimamente crível. Com efeito, sabe-se, que o artigo 239 do Código de Processo Penal permite ao Magistrado formar sua convicção com base em indício, sendo este, na definição de tal dispositivo "[...] a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação como o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias".

In casu, a prova testemunhal produzida pelos policiais militares, coerente durante

ambas fases da persecução, são aptas e idôneas para infirmarem a versão distorcida apresentada pelos réus. Nesse contexto, os indícios já elencados acima apontam que o casal praticava o odioso tráfico, em conluio. Entender de modo diverso, data venia, em total desprezo à prova indiciária, seria o mesmo que privilegiar, de modo intolerável, a impunidade.

Outrossim, não obstante o esforço da defesa, para ver reconhecida a nulidade das provas obtidas, este não é o caso. Em se tratando de crime permanente, não há se falar em pedir autorização ou mandado de busca e apreensão para ingresso no domicílio, uma vez que é legal o ingresso em residência, a qualquer hora do dia e da noite, para efetuar prisão em flagrante, sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática, sendo este exatamente o caso dos autos (art. 5º, XI, CF). Logo, estando a ré em situação de flagrância, enquanto não cessada a permanência, independente se ela estava na via pública, na calçada ou no interior da residência, é possível a violação ao domicílio mesmo sem mandado judicial. (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Juspodivm, 2017. Página 1.008)

Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO POR PESSOA NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. INGRESSO MOTIVADO POR FUNDADAS RAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. Por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual. 3. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua propriedade, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Autorização por pessoa que chama a proprietária (usucapião) da chácara de sogra e é mãe da neta da acusada. Precedentes do STF e do STJ. 4. Neste caso, o contexto fático antecedente mostra riqueza de elementos indicativos da prática delituosa, de modo que não há como acolher o pleito de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes. Ad argumentandum tantum, ainda que se desconsidere a autorização de entrada, dada por pessoa não residente no imóvel (hóspede), as demais circunstâncias que envolvem a ocorrência fornecem elementos sobejantes para permitir, em princípio, a providência tomada pelos agentes policiais. 5. De qualquer forma, a moldura fática delineada no acórdão do TJPR não permite alcançar conclusão segura quanto à alegada irregularidade da busca realizada na residência dos recorrentes. Para verificar se o ingresso dos agentes policiais no domicílio foi devidamente autorizado ou se a busca domiciliar foi precedida de averiguação quanto aos fatos narrados na denúncia anônima seria necessária ampla dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 141.544 - PR (2021/0015947-4) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de julgamento 15/06/2021) grifo nosso

No mais, para configuração do delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06, é irrelevante a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente, pois se trata de crime de conteúdo múltiplo, contemplando o núcleo do tipo penal várias condutas, tais como adquirir, trazer consigo, expor à venda, transportar, manter em depósito, guardar, oferecer, entre outras, sendo que o cometimento de qualquer uma delas já configura o delito. Contemplando o núcleo do tipo várias condutas, o fato de estar em posse desta grande quantidade de droga, por si só já é apto para configuração do crime de tráfico.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - a circunstâncias do flagrante delito, a quantidade e forma de acondicionamento da droga e o monetário

apreendido - são indícios suficientes para demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes, eliminando, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

DAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Atenuante da confissão espontânea em favor da ré.

Presente a agravante da reincidência (específica) em desfavor do réu (processo n. 0000236-66.2016.8.26.0591 - p. 74)

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Verifico a incidência da causa de diminuição de pena descrita no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em favor da ré, uma vez que preenche os requisitos para tanto. De fato, à míngua de outras provas, é primária e não há nada nos autos indicando que se dedique à atividades criminosas, tampouco que faça parte de organização criminosa.

Entretanto, ademais, no que tange ao quantum reduzido em razão da referida minorante, como a Lei n.º 11.343/2006 não oferece parâmetros específicos para sua aferição, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm concordado que para aferir o patamar de diminuição da pena, o julgador deve considerar as diretrizes do artigo 42 da Lei de Drogas. Tal dispositivo preceitua que na fixação das penas o Magistrado considerará, em preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do acusado.

No caso em tela, das quatro circunstâncias preponderantes elencadas no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, verifica-se presente natureza da droga, tendo em vista que foi apreendido cocaína, droga de fácil disseminação e de efeitos catastróficos a seus usuários e dependentes. Assim, revela-se adequada a redução na fração de 1/2.

A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C 40, INCISO VI, DA LEI N.º 11.343/06.

CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUE VISA CRIANÇA OU ADOLESCENTE.

EXCLUSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº

11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. HIPÓTESE QUE NÃO DESCARACTERIZA A FIGURA TÍPICA COMO EQUIPARADA AOS CRIMES HEDIONDOS. I - No caso em tela, excluir a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06 da pena cominada, ao argumento de que os pacientes não são os responsáveis pelo envolvimento do menor no tráfico de entorpecentes, demandaria, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (Precedentes).

II - Revela-se justificada, na hipótese, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em grau próximo do mínimo haja vista as peculiaridades do feito, notadamente o local em que efetuada a prisão, bem como a quantidade da droga que, ainda que não considerada tão expressiva, por outro lado, não foi por completo desconsiderada. [...] Habeas corpus denegado. (HC 147.157/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 21/06/2010 - grifo meu)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. QUANTUM DE REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CRIME PRATICADO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MENOR FRAÇÃO. PREVENÇÃO E REPRESSÃO. QUANTUM ACERTADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deixando de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e maior frações indicadas para a mitigação, disciplinando a doutrina e a jurisprudência que devem ser consideradas as circunstâncias previstas no art. 59 do CP e especialmente o disposto no art. 42 da Lei Antitóxicos. 2. Juízo de proporcionalidade que admite a aplicação do redutor no percentual mínimo de 1/6, de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei n.º 11.343/06 e 59 do CP, dada a natureza e quantidade de estupefaciente encontrado em poder do agente e as circunstâncias que envolveram a prática do delito, cometido dentro de estabelecimento prisional. 3. Não há bis in idem na consideração do cometimento do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional para fazer incidir a causa especial de aumento de pena

prevista no art. 18, inciso IV, da Lei n.º 6.368/76 e para negar a redução a maior na terceira etapa da dosimetria, mas apenas a utilização de um mesmo parâmetro de referência para finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido. 4. Ordem denegada. (HC 127.623/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010, grifo meu)

CONCLUSÃO

Assim, definida a tipificação do delito passo, pois, a dosimetria da pena, concomitantemente à análise das circunstâncias que influirão na quantificação da mesma.

Do sentenciado LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA BATISTA

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, o comportamento da vítima se constitui na análise do comportamento da antes ou durante o fato criminoso, aferindo se em algum momento o ofendido facilitou ou provocou a prática do ilícito. No presente caso não há vítima. Já conduta social do réu, que se traduz numa verdadeira valoração de seu relacionamento familiar, da integração do agente na comunidade e de sua responsabilidade funcional. Aqui, também não há elementos para aferição. Quanto personalidade do agente, que se refere ao seu caráter como pessoa humana, demonstrando a sua índole, forma de se portar e de ser, tem-se que poucos elementos foram coletados a esse respeito. Os antecedentes devem ser consubstanciados nos envolvimento judiciais anteriores do acusado, com leitura dada pela recente jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF - HCs 126.315; 118.977 e 162.350. STJ: REsp 1711015 RJ HC n. 210.787/RJ). Nesse caso são negativos (p. 74/75). Os motivos, entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, não cabe valoração, uma vez que inerentes ao tipo penal. As consequências do delito, consubstanciadas na intensidade lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante a vítima, não são negativas. As circunstâncias do crime são compreendidas como o *modus operandi*, ou seja, as singularidades do próprio fato. Outrossim, nos termos do art. 42 da Lei 11343/06, a natureza de droga (crack) justifica o aumento da pena base.

Assim, fixo a pena-base pouco acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a pena para 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição. Como consequência, a pena passa para 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, c/c súmula 269, do STJ, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado, porquanto o réu é reincidente. Quanto ao art. 387, § 2º, do CPP, registre-se que o réu ficou preso preventivamente no período de 24/02/2022 até 21/09/2022 (p. 445). À míngua de outros elementos que autorizem a "progressão imediata" de regime de cumprimento da pena, a despeito de considerar o tempo que o réu ficou detido, mantenho-o no regime inicial fechado. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado.

Não há que se falar em substituição da pena ou sursis.

Da sentenciada ARIELLY FERNANDA FLORENTINO GUATURA

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, o comportamento da vítima se constitui na análise do comportamento da antes ou durante o fato criminoso, aferindo se em algum momento o ofendido facilitou ou provocou a prática do ilícito. No presente não há vítima. Já conduta social do réu, que se traduz numa verdadeira valoração de seu relacionamento familiar, da integração do agente na comunidade e de sua responsabilidade funcional. Aqui, também não há elementos para aferição. Quanto personalidade do agente, que se refere ao seu caráter como pessoa humana, demonstrando a sua índole, forma de se portar e de ser, tem-se que poucos elementos foram coletados a esse respeito. Os antecedentes devem ser

consubstanciados nos envolvimento judiciais anteriores do acusado, com leitura dada pela recente jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF - HCs 126.315; 118.977 e 162.350. STJ: REsp 1711015 RJ HC n. 210.787/RJ). Nesse caso não são negativos. Os motivos, entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, não cabe valoração, uma vez que inerentes ao tipo penal. As consequências do delito, consubstanciadas na intensidade lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante a vítima, não são negativas. As circunstâncias do crime são compreendidas como o modus operandi, ou seja, as singularidades do próprio fato. Outrossim, nos termos do art. 42 da Lei 11343/06, a natureza de droga (crack) justifica o aumento da pena base. Assim, fixo a pena-base pouco acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo sua pena ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Em terceira fase, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos no patamar de 1/2, conforme fundamentação acima. Como consequência, a pena passa para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

Quanto ao regime, alterando entendimento até então seguido por este Magistrado, forte na Jurisprudência dominantes dos Tribunais Superiores (ressalvado meu entendimento pessoal), fixo, nos termos do Código Penal, o regime aberto para início do cumprimento da pena. Diante do regime fixado, nada a deliberar quanto ao art. 387, § 2º, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR os réus:

- LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA BATISTA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, estes no mínimo legal.

- ARIELLY FERNANDA FLORENTINO GUATURA, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, estes no mínimo legal.

Tendo em vista que os réus estão soltos, faculto-os o recurso em liberdade.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada.

Dispõe o art. 63, inciso I, da Lei de Drogas, que "ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I- o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias";

Considerando que não há comprovação da origem lícita do monetário apreendido nestes autos (R\$ 260,00), revelando-se produto do crime de tráfico de drogas, determino o perdimento em favor da União, conforme dispõe o artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Façam-se as anotações e comunicações que se fizerem necessárias.

Após o trânsito em julgado, façam as comunicações de praxe.

Em seguida, ao arquivo com as cautelas e devidas anotações.

P.I.C.

Panorama, 03 de outubro de 2022.

Juiz Tiago Henrique Grigorini

Titular da 2ª Vara

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA